

1502416-88.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LUCAS DADALTO SAHÃO

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... j. 05.10.2021); e

APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado (artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal). Preliminares. Inépcia da denúncia. Afastada. Nulidade do Reconhecimento Pessoal. Não configurada. Reconhecimento em harmonia com o restante da prova. Preliminar afastada. Sentença Condenatória. Roubo. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra 1ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502416-88.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502416-88.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2336998/2021 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 21891923 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 4250/21/406 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 2336998 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO AUGUSTO DOS SANTOS

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS DADALTO SAHÃO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu DENÚNCIA contra FERNANDO AUGUSTO DOS SANTOS (fls. 107/108), qualificado nos autos, dando-o como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, em tese, no dia 10 de dezembro de 2021, por volta das 14h30min, na Avenida Quinze de Novembro, 116, Centro, Itapecerica da Serra, agindo em concurso e em unidade de desígnios com indivíduo ainda não identificado, subtraiu para proveito de ambos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma corrente de ouro pertencente à vítima Maria Yamanoi de Salles.

A denúncia foi recebida em 20.01.2022 (fls. 111/113).

Regularmente citado, o denunciado apresentou defesa prévia por intermédio de defensor nomeado, refutando o teor da denúncia e arrolando as mesmas testemunhas da acusação (fls. 185/187).

Em não sendo o caso de absolvição sumária, designou-se audiência instrutória para a presente data.

Na solenidade, reafirmado o recebimento da denúncia, foram ouvidas as vítimas e as testemunhas, e procedeu-se ao interrogatório do acusado. Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público pugnou pela procedência integral da pretensão punitiva. Já a defesa advogou: (i) a absolvição do réu, por inexistência de provas da autoria delitiva; e, (ii) na eventualidade de ser acolhida a pretensão punitiva, o reconhecimento do crime na sua forma tentada; o afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal); o abrandamento da aplicação da pena, mercê da incidência da atenuante da confissão espontânea; a fixação do regime inicial semiaberto; e o direito ao recurso em liberdade (termo e mídia audiovisual da audiência).

É o relatório. Fundamento e decido.

Inexistindo questões processuais ou preliminares a serem enfrentadas, e na ausência de nulidades a serem sanadas, incursiono diretamente no exame do mérito da demanda. A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fl. 1), no boletim de ocorrência (fls. 2/7), nos autos de exibição e apreensão, de avaliação, de entrega e de reconhecimento do pertence subtraído e da arma de fogo utilizada na empreitada delitiva (fls. 19/21, 25/26, 27 e 28/29), nos laudos periciais acostados às fls. 155/157, 158/160 e 161/164 e na prova oral carreada aos autos.

A autoria também é certa, emergindo da prova vocal produzida sob o crivo do contraditório.

Em solo policial, a vítima Maria Nilsa Yamanoi de Salles declarou que: estavam a caminho do cemitério de Itapecerica da Serra para o enterro de uma tia quando pararam no semáforo; ouviu alguém batendo no vidro do seu carro; olhou e viu a arma de fogo; abaixou o vidro, quando o roubador pediu as alianças e o relógio de seu marido, que estava ao seu lado; o marido, Juliano, pediu calma ao roubador; este, então, puxou a corrente que estava no seu pescoço; em seguida, ouviu alguém dizendo “parou, parou”; neste momento, o roubador saiu da moto e apontou a arma para o homem que gritou, tendo este efetuado três disparos; tão somente notou a presença do roubador armado (termo de fl. 12).

Em juízo, reiterou, em essência, o reportado extrajudicialmente, procedendo ao reconhecimento formal do réu como sendo o roubador. Acentuou que apenas foi subtraída a sua corrente de ouro. Acrescentou que o autor dos fatos estava pilotando a moto e que havia outro comparsa na garupa (mídia audiovisual da audiência).

Tanto em solo policial (termo de fl. 13) quanto em juízo (mídia audiovisual da audiência), Juliano de Salles contou que: estavam a caminho do cemitério de Itapecerica da Serra para o enterro da sua tia quando pararam no semáforo; ouviu alguém batendo no vidro; como estava no banco do passageiro, pediu para que sua esposa abaixasse o vidro; o roubador arrancou a corrente de sua esposa e exigiu que ela entregasse a aliança e o relógio; pediu calma e, ato contínuo, ouviu alguém dizendo “parou, parou”; o roubador apontou a arma para o homem que gritou, e este atirou, porém não sabe precisar quantos disparos foram efetuados; somente percebeu a presença do roubador armado, não viu a moto nem outro comparsa.

Em juízo, não logrou reconhecer formalmente o réu como sendo um dos autores do roubo, tampouco soube dizer se havia outro sujeito como coautor. Indagado por este Magistrado, assestou que apenas a corrente de ouro de sua esposa foi subtraída. Marcos Davi dos Santos, inquirido na Delegacia de Polícia (fl. 14) e nesta sede judicial (mídia audiovisual da audiência), relatou que: estava acompanhando um lojista, para o qual presta serviço de escolta, ao Banco Itaú; o lojista entrou para depositar dinheiro; ficou esperando do lado de fora, encostado na grade próxima aos caixas eletrônicos; neste momento, entreviu uma moto, com duas pessoas, aproximar-se de um veículo; o condutor da moto sacou uma arma e bateu com esta no vidro do carro; viu a condutora abaixar o vidro, momento em que o acusado e o garupa enfiaram a mão dentro do carro para retirar pertences; ouviu a vítima gritar ao ter sua corrente arrancada à força pelo roubador; sacou, então, sua arma e deu

voz de prisão aos roubadores; o piloto apontou a arma para si, ao tempo em que efetuou dois disparos na direção daquele, alvejando-o; o garupa saiu correndo e se evadiu do local; fez contato com o CECOM, solicitando apoio e uma viatura do SAMU; o roubo estava consciente e retirou o capacete a seu pedido; quando atirou, a arma do roubo provavelmente caiu no chão e lhe foi entregue por um paisano; verificou que havia duas munições picotadas. Concitado por este Julgador, reconheceu o acusado como sendo o autor do roubo consumado que estava pilotando a motocicleta; esclareceu que havia outro sujeito na garupa do veículo; e acresceu que a arma de fogo e a res furtiva foram apreendidas em poder do réu.

Ouvido em ambas as fases da persecução penal (termo de fl. 10 e mídia audiovisual da audiência), José Batista Dantas relatou que: trabalha vendendo milho verde em frente ao Banco Santander; estava atendendo um cliente quando viu uma moto parar ao lado de um veículo e bater com uma arma no vidro; a mulher abaixou o vidro, ao que foi se esconder atrás do seu carro, pois ficou com medo; ouviu uma voz de comando, mas não entendeu o que a voz anunciou; ouviu um barulho que parecia tiro, porém não sabe precisar quantos; não visualizou a ação, porque estava escondido.

A testemunha Júlio César da Costa mencionou que: não presenciou os fatos, porque estava dentro da agência bancária do Santander; apenas ouviu uma pessoa dizendo "para, para, para" e três estampidos; ao sair da agência, percebeu que o carro estava perfurado; pegou a munição e entregou-a ao guarda civil municipal (fl. 11). Os guardas municipais Cícero Wellinton Oliveira e Carlos Prudes dos Santos narraram, em uníssono, que: foram acionados para prestar apoio ao GCM Davi, que estava envolvido em uma ocorrência de roubo no local dos fatos; chegando ali, encontraram Davi ao lado do roubo; este estava caído no solo, por ter sido atingido por dois disparos de arma de fogo efetuados por Davi; este lhes reportou que estava no banco, fazendo uma escolta, quando visualizou o roubo batendo no vidro de um carro que passava na rua; deu voz de prisão ao agente, momento em que este teria efetuado um disparo na sua direção, agressão que revidou com dois disparos; o roubo estava numa moto, que ficou jogada no solo, e o outro tripulante do motociclo teria empreendido fuga a pé; a vítima foi embora, mas estavam na posse do indivíduo, posteriormente identificado como o acusado, a corrente de ouro e um revólver calibre 38, com 4 munições intactas e 2 picotadas (fls. 8 e 9).

Em seu interrogatório judicial, o acusado confessou a prática delitiva, negando apenas que estava na companhia de outro agente.

Não ignoro que, 'mesmo que tenha sido prestada judicialmente e na presença de defensor, não tem a confissão força probatória absoluta, havendo a necessidade, para o fim de fundamentar sentença condenatória, de que seja confrontada e confirmada pelas demais provas existentes nos autos. Esta a exegese que se extrai do art. 197 do CPP, ao referir que "para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância" (grifamos). E, também, a posição agasalhada pelo STJ, ao decidir que "não se pode jamais considerá-la exclusivamente para efeito de uma condenação, sem confrontá-la com outros elementos, que possam confirmá-la ou contraditá-la.' (AVENA, Norberto, Processo Penal, 13. ed., Rio de Janeiro Forense; MÉTODO, 2021, p. 590). (Negritei).

Não descuro, ainda, que os elementos informativos coligidos na senda policial não podem lastrear, por si sós, a responsabilização criminal, nos moldes do art. 155 do CPP. Isso não significa, no entanto, que o julgador não possa deles lançar mão para robustecer sua convicção quando forem reproduzidos em juízo ou corroborados por provas produzidas no curso da ação penal, na arena do contraditório. Esse é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 1º, II E IV, DA LEI N. 8.137/1990, C/C O ART. 71 DO CÓDIGO PENAL, E 11 DA LEI N. 8.137/1990. INQUÉRITO POLICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESNECESSIDADE. TRANCAMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O inquérito policial é procedimento administrativo instaurado com a finalidade de se colherem elementos de informação acerca de autoria e materialidade de determinado crime, tão somente para o Ministério Público poder dar ou não início à

ação penal. 2. Por força de norma prevista no art. 155 do CPP, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase inquisitiva, na qual inexistente o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). O juiz pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual; por isso não se verifica nenhum constrangimento ilegal a que esteja submetido o ora recorrente, ausente, ademais, qualquer prejuízo.

(...).

5. Recurso em habeas corpus não provido. (RHC 47.938/CE, 6ª Turma, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 21.11.2017).

Assento, isto sim, que é justamente esse o caso dos autos. A confissão judicial do acusado, aliada aos seguros relatos judiciais e extrajudiciais das vítimas, das testemunhas e dos guardas municipais que procederam à diligência que resultou na prisão em flagrante do increpado, formam quadro probatório convincente e bastante para respaldar a autoria delitiva.

A vítima Maria e a testemunha Marcos Davi dos Santos reconheceram, estreme de dúvidas, o réu como o sujeito ativo da empreitada criminosa, em reconhecimento pessoal cercado das cautelas estatuídas pelos incisos do art. 226, I e II, do CPP, conclamando-se os reconhecedores a descreverem os sinais característicos das pessoas a serem reconhecidas. O reconhecimento se deu dentro das condições possíveis no âmbito da audiência realizada por meio virtual. E a res furtiva foi encontrada na posse do acusado logo após a subtração, o que gera a presunção de sua responsabilização criminal, invertendo-se o ônus da prova, reclamando justificativa inequívoca acerca da licitude da posse, ex vi do disposto no art. 156 do CPP.. É certo que, em recentes julgamentos, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que o reconhecimento de pessoas se condiciona à observância das formalidades procedimentais estatuídas no art. 226 do CPP (nesse sentido: HC 598.886/SC, Sexta Turma, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 27.10.2020; e HC 652.284/SC, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.04.2021), sinalizando uma possível mudança do entendimento até então pacífico da Corte de que a inobservância de tal procedimento importa mera irregularidade, não invalidando o ato, muito menos afetando o seu poder de convencimento ('A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "as disposições insculpidas no art. 226 do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso" (AgRg no AREsp 991.119/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1/2/2017).'

- RHC 73.151, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 21.03.2017). Mas é igualmente certo que, afora não se estar diante de verdadeiro overruling (superação da jurisprudência consolidada acerca da matéria), é amplamente majoritária no âmbito das Câmaras de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo a compreensão de que o dispositivo legal em tela não insere regras peremptórias, cuja infringência tenha o condão de macular a prova (a propósito: Apelação Criminal nº 1519491-16.2020.8.26.0228, 9ª Câmara, rel. Des. Silmar Fernandes, j. 07.06.2021; Apelação Criminal nº 0095750-20.2016.8.26.0050, 15ª Câmara, rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, j. 07.06.2021; Apelação Criminal nº 1501641-80.2020.8.26.0540, 4ª Câmara, rel. Des. Edison Brandão, j. 02.06.2021; Apelação Criminal nº 1506007-10.2020.8.26.0526, 3ª Câmara, rel. Des. Jayme Walmer de Freitas, j. 01.06.2021; Apelação Criminal nº 0020112-36.2019.8.26.0224, 2ª Câmara, rel. Des. André Carvalho Silva de Almeida, j. 29.03.2022; Apelação Criminal nº 1500452-03.2020.8.26.0626, 7ª Câmara, rel. Des. Mens de Mello, j. 28.03.2022; e Apelação Criminal nº 1503671-44.2020.8.26.0296, 13ª Câmara, rel. Des. Marcelo Gordo, j. 27.01.2022). E o reconhecimento pessoal não é o único elemento de convicção apto a comprovar a autoria delitiva – situação em que o mais atualizado precedente do STJ sobre a temática, o supracitado HC 652.284/SC, repeliu o meio de prova em foco.

Em suma: tendo em conta o conjunto de elementos constantes dos autos, a questão relativa ao reconhecimento estritamente formal do acusado em juízo pela vítima Juliano não é decisiva na definição da autoria. Concatenadas as versões das

vítimas, das testemunhas e do acusado, a autoria restou indubitosa, não vingando a tese defensiva da inexistência de provas da perpetração dos delitos. Nesse sentido: Apelação. Crimes de roubo majorado (concurso de agentes) e corrupção de menores. Sentença condenatória. Recurso da defesa. PRELIMINAR. Não é o caso de reconhecimento da invalidade do reconhecimento policial. Tampouco a falta de reconhecimento judicial macula o processo. Na realidade, tendo em conta os demais elementos constantes dos autos, a questão relativa ao reconhecimento não é decisiva na definição da autoria. MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente para firmar a condenação do acusado pelo crime de roubo. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Ressalvada a opinião do relator, esta Câmara tem entendido que o crime de corrupção de menores é de natureza material, reclamando, para sua configuração, demonstração de que o agente, de qualquer forma, contribuiu para corromper ou facilitar a corrupção do menor, não bastando o simples concurso criminoso com o mesmo. 3. Sanção que comporta redimensionamento. Apelo parcialmente provido. (TJSP, Apelação Criminal nº 1503061-87.2019.8.26.0530, 14ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Laerte Marrone, j. 05.10.2021); e APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado (artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal). Preliminares. Inépcia da denúncia. Afastada. Nulidade do Reconhecimento Pessoal. Não configurada. Reconhecimento em harmonia com o restante da prova. Preliminar afastada. Sentença Condenatória. Roubo. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato da vítima e da policial. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria. Penas corretas. Causas de aumento devidamente constatadas. Roubo praticado em concurso de agentes mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Regime inicial fechado mantido. Recurso não provido. (TJSP, Apelação Criminal nº 0009367-66.2015.8.26.0602, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Freddy Lourenço Ruiz Costa, j. 22.02.2022).

O elemento subjetivo especial do tipo (intenção de apoderar-se dos bens da vítima, visando a ter as coisas para si) ficou bem delineado na abordagem feita pelo agente, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, com o fito de suprimir a possibilidade de resistência dos ofendidos. Isto é: houve prenúncio de acontecimento desagradável, com força intimidativa, importante e sério, o que caracteriza o crime de roubo, na forma do caput do art. 157 do CP. Na lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

Grave ameaça ou violência a pessoa: a grave ameaça é o prenúncio de um acontecimento desagradável, com força intimidativa, desde que importante e sério. O termo violência, quando mencionado nos tipos penais, como regra, é traduzido como toda forma de constrangimento físico voltado à pessoa humana. Lembremos, no entanto, que violência, na essência, é qualquer modo de constrangimento ou força, que pode ser física ou moral. Logo, bastaria mencionar nos tipos, quando fosse o caso, a palavra violência, para se considerar a física e a moral, que é a grave ameaça. Mas, por tradição, preferiu o legislador separá-las, citando a grave ameaça (violência moral) e a violência, esta considerada, então, a física ou real. Na jurisprudência: STF: "Configura-se o crime de roubo quando a subtração do bem é cometida mediante violência ou grave ameaça. Impossibilidade de desclassificação para o crime de furto. É desnecessário que a violência física perpetrada cause dano à integridade corporal da vítima, sendo suficiente, para a caracterização do roubo, imposição de força física, material ou simples vias de fato capazes de minar a possibilidade de resistência à subtração do bem. Precedentes" (HC 107.147- MG, 1.ª T., rel. Rosa Weber, 17.04.2012, v.u.). (Código Penal comentado - 20. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 787). (Negrito no original).

Diferentemente do postulado pela defesa técnica, o roubo se consumou. Delito material que é, a consumação do roubo requer a perda, mesmo que momentânea, do bem subtraído (adoção da teoria da amotio). Nesse sentido se consolidou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, estampada na Súmula nº 582 do STJ ("Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata do agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse manda

e pacífica ou desvigiada"). Foi exatamente o que se passou, com a perda, ainda que por breve espaço de tempo e seguindo-se a perseguição do imputado, da corrente de ouro pertencente à vítima Maria Yamanoi de Salles.

Também ao revés da tese defensiva em sentido contrário, pelo relato da vítima e os testemunhos dos guardas municipais - que afirmaram, com veemência, que o crime foi perpetrado pelo acusado e mais um agente, a bordo de uma motocicleta -, afigura-se imperiosa a incidência da causa de aumento do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, I, do CP). Os coautores agiram previamente acordados, um aderindo à conduta do outro, sendo irrelevante que o garupa da motocicleta não tenha sido identificado.

Imperativo, ainda, o reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP). As vítimas foram taxativas ao pontuar que o agente empunhava arma de fogo, a qual foi devidamente apreendida e periciada. Ainda que assim não fosse, ficou delineada nos autos a intimidação subjetiva dos ofendidos.

Concorrendo duas causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal, o juiz pode limitar-se a uma só majoração, prevalecendo, todavia, a majorante que mais aumenta a reprimenda (art. 68, parágrafo único, do CP). Como anota CLEBER MASSON, "cuida-se de faculdade judicial. (...) Nada impede, porém, a incidência de todas as causas de aumento ou de diminuição da pena." (Direito penal: parte geral (arts. 1º a 120) - v. 1 - 15. ed. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2021, p. 619). Fica a cargo do juiz, em sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a majoração, sem que haja um critério meramente matemático, ancorado tão somente no número de causas de aumento (Súmula nº 443 do STJ).

No presente caso, não há razões que justifiquem a imposição sucessiva de dois aumentos, porquanto não há elementos que confirmem maior reprovabilidade à conduta do acusado. Houve emprego de uma única arma, e o roubo foi cometido por dois agentes, de modo que aumentos sucessivos se mostrariam exagerados, vulnerando o princípio da proporcionalidade como critério orientador da resposta punitiva. O Superior Tribunal de Justiça já acolheu esse mesmo posicionamento:

(...) na hipótese ora analisada, as instâncias ordinárias não fundamentaram, concretamente, o cúmulo de causa de aumento, com remissão a peculiaridades do caso em comento, pois o 'modus operandi' do delito, como narrado, confunde-se com a mera descrição típica da majorantes reconhecidas, não refletindo especial gravidade. Assim, respeitada a proporcionalidade da pena no caso concreto, e a intenção da Lei n. 13.654/2018, afasta-se a majorante do art. 157, §2.º, inciso II ('A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade se há o concurso de duas ou mais pessoas'), aplicando-se apenas a do art. 157, §2.º-A, inciso I ('A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços)' se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo'), ambas do Código Penal (...) (HC 472.771/SC, Quinta Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.12.2018).

Na mesma direção se pronunciou recentemente o Tribunal de Justiça de São Paulo: Apelação. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo (artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal). Insurgência da Defesa pleiteando a absolvição do acusado nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento do aumento aplicado à pena em virtude do emprego da arma de fogo e a aplicação de apenas um aumento na terceira fase da dosimetria, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, além da fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento da pena corporal e a aplicação da detração penal. Impossibilidade da aplicação da absolvição pleiteada. Robusto conjunto probatório que impõe a manutenção da condenação do réu. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelas provas dos autos. Penas redimensionadas. Reduzido aumento aplicado à pena-base em virtude das consequências do crime. Causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo devidamente comprovada. Instrumento não apreendido. Irrelevância. Prova oral consistente no uso daquele armamento durante a ação delitiva. Aplicação do art. 167 do CPP. Precedentes do TJSP. Na fase intermediária, reconhecida a agravante da reincidência ostentada pelo acusado. Na derradeira etapa, foram aplicadas equivocadamente duas causas de aumento de pena (concurso de agentes e emprego de arma de fogo). Vigência da Lei 13.654/18. Aplicação do art. 68 do Código Penal. Adequação da pena que foi reduzida. Regime

fechado mantido ante a gravidade do crime praticado e a reincidência em crime patrimonial ostentada pelo réu. Pedido de detração que deve ser apreciado pelo juízo das execuções. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Criminal nº 0091137-83.2018.8.26.0050, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Osni Pereira, j. 06.05.2021). (Negritei).

Aplicarei, pois, apenas o aumento na fração de 2/3, referente ao emprego de arma de fogo na ação criminosa (art. 157, § 2º-A, I, do CP).

Realço, por oportuno, que houve crime único, e não concurso formal próprio de roubos (art. 70, caput, do CP), haja vista que a grave ameaça e a lesão ao patrimônio se endereçaram exclusivamente a Maria Yamanoi de Salles. Nesse aspecto: AGRADO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. PARTICULARIDADE DO CASO. CRIME ÚNICO CONFIGURADO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO DIVERGE DA ORIENTAÇÃO FIRMADA EM DIVERSOS JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. AGRADO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na hipótese, o Tribunal local ressaltou que, "conquanto dois tenham sido os patrimônios malferidos, isto é, o do estabelecimento (dinheiro) e de seu proprietário (celular), que sobre os bens exercia além da propriedade a posse direta, o prejuízo seria de única pessoa física".

2. O entendimento exposto no acórdão impugnado está em conformidade com a orientação firmada em diversos julgados desta Corte Superior, no sentido de que não há concurso formal se a violência ou grave ameaça exercida no crime de roubo se voltou contra uma só vítima, que, sozinha, exercia a posse de bens de sua propriedade e de terceiros.

3. No mais, como a pessoa natural lesada era o proprietário do supermercado em que ocorreu o roubo, é razoável que se admita ter havido, na prática, uma única lesão patrimonial.

4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp 1.782.251/GO, Sexta Turma, relª. Minª. Laurita Vaz, j. 05.02.2019); e

Embargos infringentes. Roubo de patrimônio diversos portados por única pessoa - Reconhecimento de crime único. Admissibilidade. Entendimento firmado pelo STJ. Regime inicial semiaberto para o corréu Flávio. Cabimento. Circunstâncias judiciais favoráveis, pena-base no mínimo legal. Inteligência da Sum 440 do STJ. Embargos infringentes acolhidos. (TJSP, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0042150-50.2017.8.26.0050/50000, 2ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Luiz Fernando Vaggione, j. 23.04.2020).

Logo, ausentes excludentes de ilicitude, dirimentes de culpabilidade e causas de extinção da punibilidade, a responsabilização do acusado como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, é de rigor.

Passo a dosar a pena aplicável ao réu, em atenção ao sistema trifásico perfilhado pelo Código Penal (arts. 59 e 68).

Na primeira fase, analisadas as circunstâncias judiciais alinhadas pelo art. 59 do Código Penal, verifico que: a culpabilidade é normal à espécie delitiva; consoante se extrai da certidão de fls. 144/147, o réu ostenta duas condenações criminais anteriores transitadas em julgado por receptação (art. 180 do CP), proferidas nos autos das ações penais nºs 1515498-62.2020.8.26.0228 e 1502474-62.2019.8.26.0628, não alcançadas pelo período depurador (art. 64, I, do CP, a contrario sensu), de sorte que valorarei uma nesta etapa como mau antecedente, e, a outra, na fase posterior da aplicação da pena, a título de reincidência (Súmula nº 241 do STJ); não há maiores informações sobre a conduta social e a personalidade do agente, não ensejando maior desvalor; os motivos são inerentes ao elemento subjetivo do tipo penal, não merecendo valoração negativa; as circunstâncias e as consequências do crime também são inatas ao tipo penal, no aspecto objetivo, e/ou compreendem majorantes, não comportando avaliação negativa, sob pena de bis in idem; e o comportamento da vítima é circunstância neutra ou favorável.

À vista da circunstância judicial desfavorável (mau antecedente), exaspero a sanção penal em 1/8, fixando a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, incidem as circunstâncias atenuante da confissão espontânea perante a autoridade judicial (art. 65, III, "d", do CP), ainda que parcial,

utilizada para a formação do convencimento deste julgador (Súmula nº 545 do STJ), e agravante da reincidência (arts. 61, I, e 63, ambos do CP) – consoante já acentuado.

Atento à compreensão pacificada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp nº 1.154.752, em 26.05.2012, compenso a atenuante com a agravante, posto serem igualmente preponderantes, a teor do art. 67 do CP, remanescendo a pena tal qual fixada na primeira fase.

Na terceira fase, não há causas de diminuição a serem consideradas. Em contrapartida, concorrem as causas de aumento do § 2º, inciso II, e do § 2º-A, inciso I, do art. 157 do Código Penal, de modo que procedo à majoração de 2/3, conforme supra motivado, passando a dosar a pena em 7 anos e 6 meses de reclusão e 18 dias-multa, que torno definitiva.

Ausentes maiores informações sobre a situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato (arts. 49, § 1º, e 60, ambos do CP).

Estabeleço o regime fechado para início do cumprimento da pena corporal, único admitido para a hipótese, posto se tratar de réu reincidente, e considerando o quantum da reprimenda (art. 33, § 2º, do Código Penal).

O tempo de prisão provisória não é suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento da pena corporal (art. 387, § 2º, do CPP). Como vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "com o advento da Lei 12.736/12, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional. Forçoso reconhecer que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado" (HC n. 443.419/SP, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05.06.2018, DJe 12.06.2018). O réu está preso desde 23.03.2022 (fl. 145), não havendo margem para a alteração do regime penitenciário (art. 112 da LEP).

Eventuais pleitos de progressão de regime e detração penal devem ser formulados perante o juízo das execuções, competente para tanto, porque ausentes notícias sobre a real situação carcerária do acusado (art. 112, § 1º, da LEP). Nessa linha: Apelação. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo (artigo 157, § 2º, inciso II e §2ºA, inciso I, do Código Penal). Insurgência da Defesa pleiteando a absolvição do acusado nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento do aumento aplicado à pena em virtude do emprego da arma de fogo e a aplicação de apenas um aumento na terceira fase da dosimetria, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, além da fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento da pena corporal e a aplicação da detração penal. Impossibilidade da aplicação da absolvição pleiteada. Robusto conjunto probatório que impõe a manutenção da condenação do réu. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelas provas dos autos. (...). Regime fechado mantido ante a gravidade do crime praticado e a reincidência em crime patrimonial ostentada pelo réu. Pedido de detração que deve ser apreciado pelo juízo das execuções. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP, Apelação Criminal nº 0091137-83.2018.8.26.0050, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Osni Pereira, j. 06.05.2021). (Negritei).

Inviáveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, seja pela quantidade da sanção imposta, seja em razão da reincidência do acusado (arts. 44 e 77 do Código Penal).

Denego o apelo em liberdade. Da gravidade concreta do crime praticado por réu reincidente, com emprego de arma de fogo, emerge que, caso solto, a liberdade dele poderá colocar em xeque a tranquilidade social, porquanto terá os mesmos estímulos para delinquir. A par disso, a custódia cautelar se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal, dado que o réu já se evadiu em uma oportunidade do estabelecimento prisional, havendo justificado receio de que novamente se evada do distrito da culpa, impedindo, assim, a execução da pena imposta. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. Homicídio qualificado. Pedido de revogação da prisão preventiva. Alegação de nulidade da citação por edital. Inocorrência.



Diversas diligências realizadas nos autos a fim de localizar o acusado. Paciente que permaneceu foragido e, após mais de três anos dos fatos, compareceu na repartição policial e indicou endereço. Ausência de localização do paciente no endereço por ele declinado nos autos. Necessidade de se garantir a aplicação da lei penal. Circunstâncias que até o momento impõem a manutenção da decretação da prisão preventiva. Ordem denegada. (TJSP, Habeas Corpus Criminal nº 2270379-16.2021.8.26.0000, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Leme Garcia, j. 17.12.2021).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia para CONDENAR o réu FERNANDO AUGUSTO DOS SANTOS, já qualificado nos autos, como incurso no crime do art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, às penas de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 18 dias-multa, no valor mínimo unitário (1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos).

O acusado respondeu ao processo preso, e, permanecendo os motivos justificadores da custódia cautelar, deverá continuar custodiado. Haverá, assim, de recorrer preso preventivamente (art. 387, § 1º, c.c. art. 312, ambos do CPP), de maneira que o recomendo, desde logo, ao estabelecimento prisional em que se encontra recolhido. Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal (art. 387, IV, do CPP), em virtude da ausência de pedido expresso da acusação, e porque os bens subtraídos foram recuperados.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).

Contudo, a respectiva exigibilidade ficará suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da dicção conjunta dos arts. 3º do CPP e 98 a 102 do CPC, pois ora lhe concedo o benefício da assistência judiciária gratuita.

Intimem-se as vítimas do teor deste julgado (artigo 201, § 2º, do CPP).

Expeça-se certidão de honorários advocatícios em favor do nobre patrono nomeado, no valor máximo previsto na tabela vigente.

Com o trânsito em julgado desta sentença: (a) lance-se o nome do réu no rol de culpados; (b) oficie-se ao TRE do domicílio eleitoral do acusado para fins de suspensão dos direitos políticos (art. 15, III, da CF) e para efeitos de inelegibilidade; (c) oficie-se ao IIRGD para cadastro dos antecedentes; (d) expeça-se a documentação necessária para a execução das penas; e (e) remetam-se os autos à contadoria judicial para elaboração do cálculo da multa, intimando-se, em seguida, o acusado para recolhimento, em 10 dias, do valor pecuniário devido (art. 50 do Código Penal).

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Itapeccerica da Serra, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA